

某公司作为代运营公司，对王某的真实意思表示是应当知道的。故根据合同双方的真实意思表示，合同中的粉丝应为真实粉丝。二是当合同双方对粉丝质量约定不明时，应作出正向价值取向的理解。清理虚假粉丝会保护用户免受垃圾行为的骚扰，并远离钓鱼网站、虚假营销等带来的潜在威胁，用户也能通过真实的粉丝量判断账号的价值，这也将鼓励更多账号创造出优质的内容和服务，从而提升网络平台的整体质量，为用户提供更多有价值的内容。故真实粉丝是创造优质网络环境的应有之义，也是合同内涵的应有之义。王某自2021年8月2日至11月21日运营涉案账号期间没有发布作品，且在粉丝没有大幅增长的情况下，于2021年11月22日通过某平台检测出违规粉丝144203个，足以认定该144203个违规粉丝系某公司运营所导致。故某公司实际完成增长粉丝数量 约为15.8万。.

关于王某提出异议是否超出合理期限。某公司作为代运营公司，相对于王某来说，具备更专业的社交平台运营知识，应当知道涉案账号的部分粉丝是不符合约定的。故王某对某公司提出异议的期间不受合理期间的限制。即使认定王某应当在交付之日就使用自助“清粉”功能进行检测，那么从交付的2021年8月至王某提出异议的2021年11月为四个月，相对于涉案账号的使用期限来说也是比较短暂的期间。故不能认定王某提出异议超出合理期限。综上，根据合同约定，某公司应退还王某50%的服务费用，即10.5万元(21万元/2)。

某公司已于2022年10月24日自行清算后注销，王某的债权确定时间在该公司注销登记之后，属于可补充申报的债权。四被告作为该公司的股东均未实缴出资，应在未缴出资范围内对公司债务承担连带清偿责任。故周某、刘某、孟某、马某应在未缴出资范围内对王某10.5万元的债权及违约金承担连带清偿 责任。

河北省石家庄市裕华区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十四条、第六百二十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十四条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、周某(在未出资12.5万元范围内)、刘某(在未出资17.5万元范围内)、孟某(在未出资10万元范围内)、马某(在未出资10万元范围内)于本判决生效之日起十日内退还王某合同款10.5万元,并支付违约金(违约金以10.5万元为基数,自2021年11月22日起至实际付清之日止,按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心2023年4月即原告起诉时公布的一年期贷款市场报价利率计算);

二、王某于本判决生效之日起十日内支付周某、刘某、孟某、马某装修款4050元;

三、驳回王某的其他诉讼请求;

四、驳回周某、刘某、孟某、马某的其他反诉请求。

周某、刘某、孟某、马某不服一审判决,提起上诉。

河北省石家庄市中级人民法院经审理认为:同意一审法院裁判意见,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

在当今网络信息时代,数字经济运行新模式的不断涌现给民商事审判提出了新要求,也带来了新挑战。如何坚持鼓励和规范并重,既能为激发数字经济活力留出空间,又能助力营造干净安全的法治化网络营商环境,是司法实践中值得探讨的问题。

本案的核心在于,如何审查认定某软件账号代运营公司的服务成果是否符合合同约定。合理审查该服务成果的属性才能促进代运营经济活动的有序良性发展,激发数字经济的健康活力。代运营公司的服务成果作为一种智力成果,目前还没有相应的国家标准、行业标准或通常标准,因而在运营合同对质量标准没有明确约定的情况下,无法适用《中华人民共和国民法典》第五百一十条、第五百一十一条的规定来确定服务成果的质量。结合代运营经济活动的实际履行情况,根据合同法律法规的相关规定,笔者认为可以按照以下审理思路

对代运营的服务成果是否符合合同约定进行审查认定：

一、代运营的服务成果形式上是否符合合同约定

审查代运营的服务成果是否符合合同约定首先应进行形式上的审查。代运营合同大多约定服务提供方在服务需求方账号上一定期限内发布短视频的数量、粉丝量或直播达到的观看量、产品销售量等。这些数据可以较为直观地呈现，若代运营的服务成果形式上与合同约定内容不一致，则可以按照合同约定判定服务提供方的违约责任。若代运营的服务成果形式上与合同约定内容一致，可再进行下一步的深入审查。

二、代运营的服务成果实质上是是否实现合同目的

代运营的服务成果虽具有一定程度的直观体现，如粉丝数量、直播观看量等，但其作为一种虚拟资产，还涵盖账号影响力等无形资产的价值。而形式上的审查并不能涵盖无形资产价值的审查。因此，在审查认定代运营的服务成果是否符合合同约定时，在形式审查的基础上，还应进一步从实质上对服务成果的价值进行审查。笔者认为，该实质审查可以结合服务成果是否能够实现合同目的进行判定。

在司法实践中，代运营合同一般很少明确约定合同目的，但可以通过日常生活经验法则进行推定。在代运营经济活动中，服务需求方的真实目的无疑是增加账号的影响力，服务提供方作为专业的代运营服务方，对服务需求方签订合同的目的是明知的，故代运营合同双方的合同目的均应为实现服务需求方影响力的提升。

因此，当代运营的服务成果形式上已经符合合同约定后，还应进一步审查该成果是否达到增加账号影响力的目的。比如，在本案中，某平台认定的涉案账号虚假粉丝数量的增长虽然能够实现粉丝数据上升的直观性，表面上有增加账号吸引力的成果，但实质上会使涉案账号受到“垃圾行为”骚扰等多种不良影响，甚至导致账号被封禁，显然不能实现代运营合同的目的。类似于本案的社交媒体账号的影响力除体现在粉丝数量的增长外，还可能涉及作品点赞量、互动指数、直播间观看粉丝量等媒体运营考核数据以及产品销售业绩数据，此

类因素均应按照上述思路纳入审查范围，综合判断涉案因素呈现的服务成果实质上是否实现了合同目的，以客观、合理认定服务提供方是否全面履行了合同义务。

三、服务需求方对代运营服务成果检验期限的认定

经审查认定服务成果不符合合同约定时，还应继续审查服务需求方对代运营服务成果提出异议的期间，即检验期限是否在合理期限内。《中华人民共和国民法典》对于服务合同的检验期限没有具体规定，根据本法第六百四十六条“法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照适用买卖合同的有关规定”之规定，亦可以参照适用本法第六百二十一条关于买受人检验义务的规定，服务需求方认为服务成果不符合要求的，应当在检验期限内将此情形通知服务提供方。若服务需求方怠于检验和通知，则视为服务成果符合合同约定。那上述检验期限在代运营经济活动中应如何认定？笔者认为，根据合同约定及履行情况的不同，应区别审查认定。

当代运营合同未约定检验期限时，应首先确定检验的合理期限，即发现成果瑕疵所需时间和进行瑕疵通知所需时间。其中，发现瑕疵所需时间极限可界定为服务需求方应当发现瑕疵所需要的时间。在代运营经济活动中，对服务成果形式上瑕疵的审查方式较为容易和直观，服务需求方应在收到服务成果时即时进行审查并通知；对服务成果实质上是否实现合同目的的审查，发现瑕疵所需要的时间应区分不同种类服务成果检测的难易程度，并结合服务成果的使用程度、服务需求方的受益程度等因素综合判定。确定合理期限后，服务需求方也未在合理期限内通知成果瑕疵的，应当适用《中华人民共和国民法典》第六百二十一条第二款关于最长质量异议期的规定，即服务需求方在收到服务成果之日起二年内未通知服务提供方的，视为服务成果符合合同约定。另外，服务提供方知道或应当知道提供的服务成果不符合约定的，服务需求方不受上述合理期限及最长质量异议期的限制。

综上，在代运营经济活动中，审查认定服务成果是否符合合同约定首先需要服务成果形式上是否符合合同约定进行审查；之后需对服务成果实质上是

否符合增加账号影响力等合同目的进行审查。若服务成果在形式上和实质上均符合合同约定，则认定服务提供方全面履行了合同义务；若服务成果在形式上或内容上有任意一项不符合合同约定或合同目的时，还应结合代运营活动的性质和履行情况对服务需求方提出质量异议的期限进行审查，并根据其异议提出时间是否在合理期限内，认定服务成果是否符合合同约定。

编写人：河北省石家庄市裕华区人民法院 郭爱民 甄宇音

预付式健身会员可因私教离店主张解除合同

—— 郑某诉某健身公司服务合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第二中级人民法院(2023)沪02民终11664号民事判决书

2. 案由：服务合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 郑某

被告(上诉人): 某健身公司

【基本案情】

2021年9月至12月，郑某和某健身公司签订3575号、3583号、3637号、3676号、3838号、3839号共六份私教健身合同。其中，3637号、3676号合同分别系由3575号、3583号合同升级而来。

六份合同名称均含“私教”字样，均含课程次数及有效期的约定，合同均为预付式消费。六份合同第一条第五项均约定：会所将根据您的身体情况及要

求，提供团队服务。如您指定的私人教练因休假、调店或离职等原因无法完成课程时，会所可以为您更换适合的私人教练。第八项中约定：私教合同签订之日起，如会员单方面提出解除训练课程，视为违约，须按照课程剩余金额的30%支付违约金。2022年2月12日之前基本由徐某或欧某为郑某上课，此后二人均至其他门店。

因某健身公司变更私教并作出其他安排，郑某于2022年2月12日在微信群中提出异议，并向欧某发送微信表示要求退费。后于2022年2月18日询问徐某如何办理退费，于2022年2月22日询问欧某课程事宜，于2022年3月12日再次询问徐某能否为其办理退款。郑某于2022年2月12日至3月12日8次接受其他私教的课程服务，末次上课时间为2022年3月12日。全部合同剩余课程费用为111560元。

郑某认为，双方曾约定由徐某、欧某为其提供私教服务，因二人已至其他门店，故某健身公司在未进行事前沟通的情况下通知郑某要更换教练，属违约行为。郑某曾于2022年2月12日向某健身公司提出解除合同并退还剩余课程费用。后因双方协商未果，故郑某起诉要求确认六份合同已于2022年2月12日解除，并要求某健身公司返还111560元及利息。

【案件焦点】

郑某是否有权解除六份合同，以及某健身公司应向郑某退还课程费的数额。

【法院裁判要旨】

上海市虹口区人民法院经审理认为：因郑某于2022年2月12日之前的授课私教相对固定，故虽然六份合同中并未明确约定私教人选，亦应推定双方曾作出明确约定。六份合同第一条第五项之约定，属违反《中华人民共和国民法典》第四百九十七条第三项所规定的情形，应为无效格式条款。且六份合同具有较强的人身属性，不宜强制履行。因徐某、欧某至其他门店，郑某不愿再接受某健身公司的私教课程服务，故合同目的已无法实现，郑某享有合同解除权。在2022年2月12日至3月12日，虽然郑某有退款之表述，但其解除合同的意

思并不明确，且仍有上课记录，故双方合同并未解除。郑某于2022年3月12日明确向徐某要求退费，此后亦未再上课，但此时3838号合同有效期已届满，3575号合同、3583号合同因升级而终止，故仅3637号合同、3676号合同和3839号合同于2022年3月12日解除。

六份合同第一条第八项之约定，属违反《中华人民共和国民法典》第四百九十七条第二项所规定的情形，应为无效格式条款。加之，原为郑某提供私教课程服务的健身教练徐某、欧某确已至其他门店，郑某因此提出解除合同并要求退费，并非出于恶意，且郑某已尽力协商并多次尝试接受其他私教的课程服务。故此，3637号合同、3676号合同和3839号合同解除后，某健身公司应当向郑某退还剩余全部课程费用109640元，且郑某无须支付违约金。

上海市虹口区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百一十九条、第四百九十六条、第四百九十七条、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百六十六条之规定，判决如下：

- 一、确认3637、3676、3839号私教健身合同于2022年3月12日解除；
- 二、某健身公司于判决生效之日起十日内，向郑某退还109640元；
- 三、驳回郑某的其余诉讼请求。

某健身公司不服一审判决，提起上诉。

上海市第二中级人民法院经审理认为：六份合同中约定的某健身公司可更换教练、郑某撤换教练需经公司允许、郑某单方提出解除训练课程视为违约并应支付课程剩余金额30%的违约金等格式条款应属无效。双方签订的合同均系私教合同，该合同具有很强的人身属性。徐某及欧某均离开门店后，郑某订立合同的目的已无法实现。郑某主张解除合同，并非违法解除，无须支付违约金。鉴于部分合同期限已因届满或升级而终止，故一审法院判决双方剩余合同解除，由某健身公司退还剩余私教课程费用共计109640元，并无不当。

上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

处理私教合同案件时，在判断私教合同条款的效力、确定合同解除时间及违约责任承担等方面，应遵循明晰处理思路。首先判断合同是否明确约定私教人选，其次判断合同是否可解除及解除时间，最后确定退费的数额。

一、判断是否明确约定私教人选

实践中，有的健身合同明确约定了私教人选，此类合同当然属于私教合同。也有健身合同没有明确约定私教人选，但合同名称及条款约定中涉及私教之内容。从合同性质角度出发，后者亦应属于私教合同。由此引出私教合同可区分为明确约定私教的合同和未明确约定私教的合同。对于后者的判断标准，在商家抗辩称合同中虽有私教签名，但实质为其履行销售职责时，法院尚可根据实际授课情况、合同名称及约定内容以判断双方是否已确定私教人选^①，故其中的“实际授课情况”是核心问题。

当会员以选定私教已离职，要求解约退费时，商家往往以书面合同未约定私教人选、书面合同约定商家可更换私教为由主张继续履行合同。因此，法院应当审查会员的上课记录、会员与商家或私教的聊天记录等，以对双方是否约定私教人选作出认定。在授课私教相对固定的情况下，即应以高度可能性标准认定会员曾与商家明确约定私教人选。

二、判断是否可以解除合同

由“健身房有权更换私教”条款引发争议后，法院存在多种处理意见。一种观点认为，该条款免除己方责任、排除对方主要权利，属无效格式条款。^②另一种观点认为，相关条款亦赋予会员有要求更换教练的权利，并不存在排除或限制一方的权利，减轻或免除己方义务的情形^③，故不认为相关条款无效。

本案例采第一种观点。因会员选择私教合同的核心目的是在私教的指导下

^①参见重庆市第四中级人民法院(2022)渝04民终1225号民事判决书。本案脚注所列文书均来自中国裁判文书网，最后访问时间：2025年1月20日。

^②参见吉林省长春市中级人民法院(2020)吉01民终5111号民事判决书。

^③参见浙江省杭州市中级人民法院(2020)浙01民终3997号民事判决书。

健身，故双方合同中会员的主要权利系由其本人确定私教。而“有权更换私教”条款系将会员的主要权利予以排除，故为无效格式条款。

考虑到私教合同有较强的人身属性，商家本应按照双方的真实合意履行合同。在会员与商家约定私教人选、私教已离店、商家无权随意更换私教的情况下，因会员对商家的信赖基础丧失，且会员订立合同的目的不能实现，故其应享有合同解除权。

三、判断商家向会员退费的数额

本案六份合同均约定“如会员单方面提出解除训练课程，视为违约”。对此，多数观点认为，此种条款亦属于无效格式条款，相关约定存在不合理免除己方责任、加重对方责任的情形。^①也有观点认为，违约条款系合同中的常见条款，并无免除己方责任、加重对方责任、排除对方主要权利的情形，故并非无效格式条款。^②

本案例采第一种观点。该类条款系在“一经售出，概不退款”类条款的基础上产生，其违约条件过于苛刻。如该条款有效，则无论商家出现何种履约瑕疵，亦不论是否出现不可抗力，会员都不能以商家违约为由主张全额退款。因而，此类条款与“一经售出，概不退款”条款的实质相同，属于不合理加重会员责任，故为无效格式条款。

在会员享有合同解除权且向商家提出解除合同时，会员并无违约行为，故商家应向会员退还全部剩余课时费，且会员无须向商家支付违约金。

编写人：上海市虹口区人民法院 徐丹阳

^①参见北京市第一中级人民法院(2020)京01民终5922号民事判决书。

^②参见江苏省南京市中级人民法院(2020)苏01民终7406号民事判决书。

商家未经消费者同意将预付式消费合同义务 转移给第三人，消费者有权拒绝并解除合同

—— 骆某诉夏某服务合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市北碚区人民法院(2023)渝0109民初9829号民事判决书

2. 案由：服务合同纠纷

3. 当事人

原告：骆某

被告：夏某

【基本案情】

2022年6月28日，骆某参加了夏某经营的养生馆“365元减肥1年(保持到店300次以上减10斤)”活动。因另行购买的100元2次塑形体验效果较好，又于当月购买了1980元塑身套盒服务，共计15次，包含手法、仪器配合套盒产品。2022年9月6日，骆某在养生馆通过案外人曾经理的介绍花费14000元向夏某购买包干服务包括塑形、疏通经络、除湿和排毒、减肥至120斤，并且融入之前365元减肥1年的促销活动、1980元塑身套盒服务。在此之前，夏某已向骆某提供8次塑身服务。此后，夏某向骆某提供每天三小时的减肥、塑形、除湿排毒项目服务，一段时间后因骆某形体达到较好效果，塑形频率变更为一周一次。至2022年11月前，骆某体重为139.8斤，与最初体重减少10.6斤。

后因养生馆员工身体不适以及加盟公司撤销其经营的养生馆，夏某无法再向骆某提供服务。

骆某认为，截至2023年2月，其只减肥10.6斤，后养生馆关闭，夏某以各种理由推诿不再提供减肥服务，并提出由自己完全不了解的第三方继续履行合同，构成违约，故诉请法院解除双方服务合同关系，判令夏某返还扣除试减10斤活动的365元后的16080元费用。

夏某辩称，夏某无法继续为骆某提供服务亦提出解决方案，即由距离近600米处的同品牌分店继续履行。对已提供服务对应的项目及应扣减的费用，夏某认为，已经减去的10.6斤不能视为365元活动所对应的服务成果，同期365元一年减肥客户单次减肥流程简单，仅为手法加精油减肥，需要很长时间才能出效果。而骆某仅在两个月内就减重10.6斤，且身形有明显的变化，系使用包干服务塑身产品和塑形仪器的结果，故有理由认为骆某付款14000元减至120斤的要求是除“365元减10斤”活动的单独邀约，在约定之初也与骆某进行了明确。综上，应驳回原告骆某的诉讼请求。

【案件焦点】

骆某是否有权解除合同，并要求夏某退还相应款项。

【法院裁判要旨】

重庆市北碚区人民法院经审理认为：关于商家未经消费者同意将预付式消费合同义务转移给第三人，消费者是否有权拒绝并解除合同，同时要求商家退还相应款项。首先，预付式消费服务合同属于无名合同，当然适用《中华人民共和国民法典》第五百六十三条关于合同法定解除的规定，消费者得以在不可抗力、预期违约、迟延履行、其他违约行为、法律规定的其他等情形下行使法定解除权。其次，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十三条的规定，经营者未能按照约定提供商品或者服务的，消费者有权要求经营者退回预付款及其他损失。2024年7月1日起施行的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十二条也明确规定，经营者未按照约定提供商品或者服务

的，应当按照消费者的要求履行约定或者退还预付款。经营者决定停业或者迁移服务场所的，应当提前告知消费者和公告有效联系方式。消费者依照国家有关规定或者合同约定，有权要求经营者继续履行提供商品或者服务的义务，或者要求退还未消费的预付款余额。且《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》^①第十三条第一款第二项规定，经营者未经消费者同意将预付式消费合同义务转移给第三人，消费者请求解除预付式消费合同的，人民法院应予支持。

本案中夏某因为自身原因(经营不善以及加盟公司不再与其合作)无法继续履行涉案合同，且该合同的履行具有较强的人身属性，骆某基于对原有门店服务的信任与夏某建立合同关系，有理由拒绝到其他不了解的门店继续接受服务，据此，对于骆某解除合同的诉求，本院予以支持。

至于解除合同的时间，依据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条第二款的“当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除”之规定，在本案诉讼前，双方之间一直在沟通涉案合同的履行，并未协商一致解除合同，故本院以夏某收到起诉状副本的时间即2023年9月6日作为解除合同的时间。

至于退还金额。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十六条第一款、第二款的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但当事人另有约定的除外。根据查明的事实，骆某100元购买塑形体验卡，2次塑形体验，夏某已履行完毕，不存在退款。1980元塑身套盒服务，在支付14000元之前已享受8次服务，之后与“365元减1年”一并融入14000元的服务合同中。综上，根据夏某提供服务情况、违约程度、骆某损失情况，本院酌情支持夏某向骆某退还服务费8000元，超过部分，本院不予支持。

^①注：本解释自2025年5月1日起施行。

【法官后语】

近年来,预付款方式消费在美容美发、健身、减肥、教培等行业领域逐趋流行。此类预付式消费服务合同的特殊性在于合同的形成及后续履行以信赖关系为基础,并具有预付性、持续性、不可替代性及人身专属性等特征。同时,与一般商品买卖不同,服务具有无形性及返还困难性等特性,因而一旦出现高额预付后商家“跑路”或变更等情形,消费者退款难现象并不罕见,司法实务中引发的纠纷也时有发生。

本案审理的关键在于预付式服务提供方因经营不善等原因难以继续履行原合同义务,将合同义务转移至第三人,消费者是否能主张解除权,合同相对方能否以更换服务方来阻却消费者的解除权。

一、从法律规定层面分析

《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第二十二条明确规定,经营者未按照约定提供商品或者服务的,应当按照消费者的要求履行约定或者退还预付款。经营者决定停业或者迁移服务场所的,应当提前告知消费者和公告有效联系方式。消费者依照国家有关规定或者合同约定,有权要求经营者继续履行提供商品或者服务的义务,或者要求退还未消费的预付款余额。《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款第二项规定,未经消费者同意将预付式消费合同义务转移给第三人,消费者请求解除预付式消费合同的,人民法院应予支持。

二、合同特殊性层面分析

服务合同具有较强的人身属性,合同的履行需要相对方的配合,不属于可强制履行的合同类型。消费者往往是基于对门店服务能力的信任选择与其订立合同,如发生商家变更经营场所、更换经营者、变更服务人员至消费者信赖丧失等情形的,消费者有权拒绝“更换服务方”的替代服务方案。

综上,预付款消费服务模式中,经营者决定停业或迁移服务场所的,消费者享有解除权并有权要求经营者退回未消费的预付款余额。

值得注意的是,服务类产品一般系非基本生活消费必需品,属于较高层次

消费，且这类预付卡充值金额往往较大，一旦交付预付款，因信息不透明处于劣势地位的消费者往往容易陷入被动，面临大额消费资金被套牢的风险。有鉴于此，法官也提醒大家谨慎选择商家，尽量避免大数额充值，在签订服务合同时，应根据《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》及《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，与服务者签订并认真审阅书面合同并保留消费凭证。

编写人：重庆市北碚区人民法院 王璟玥 李开

代驾平台在无合同约定情况下封禁司机账户应承担违约责任

——尚某诉某信息技术公司合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终5588号民事判决书

2. 案由：合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 尚某

被告(被上诉人): 某信息技术公司

【基本案情】

2021年11月，尚某通过某信息技术公司的应用软件注册成为代驾司机，并线上签订《用户服务协议(司机端)》，其中约定某代驾平台，该代驾平台为某信息技术公司持有并负责运营的代驾服务平台，本平台为符合代驾承运资质的代驾司机提供来自代驾服务需求用户的订单匹配、派送及相关服务。

注册后，尚某作为其代驾司机，开始接单代驾。

2022年2月25日，尚某在某信息技术公司代驾工作的应用软件账户被封禁。

2022年8月23日，当庭经双方确认尚某的上述账户已被解禁。

2022年10月9日，尚某称其上述账户又被封禁，某信息技术公司称因其未按管理需要录入代驾司机的身份信息，故账户暂被封禁。

另查明，尚某于2021年12月通过某科技公司应用软件注册为代驾司机。

2022年2月5日，尚某通过某科技公司应用软件接单为用户提供服务。在服务过程中，尚某与用户发生争执。尚某遂与某科技公司客服沟通要求取消订单。某科技公司将该订单取消后，尚某另行接单。此后，某科技公司客服告知尚某已被用户投诉并报警，该公司将依据公安机关调查结果对投诉予以处理。2022年2月7日，某科技公司将尚某工作账户封禁并自该账户扣除500元作为支付用户的损害赔偿金。后尚某将某科技公司起诉至法院。

【案件焦点】

某信息技术公司对尚某采取封禁账户的行为是否构成违约，及若成立违约，对尚某的经济损失赔偿应如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：依法成立的合同，受法律保护。当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，尚某与某信息技术公司签订的《用户服务协议(司机端)》系双方的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应属合法有效。从《用户服务协议(司机端)》和尚某的履行情况来看，某信息技术公司在尚某并无过错的情况下对其账户自2022年2月25日至8月22日持续采取限制措施的行为已构成违约。

某信息技术公司辩称因尚某在案外网约车平台(科技公司)曾发生纠纷，

后平台基于风险，对尚某的账户进行封禁，并且某信息技术公司表示其已授权平台对其进行管理。根据《用户服务协议(司机端)》的约定，虽尚某在案外网约车平台上存在与乘客发生争执被投诉的行为，但该行为并不能直接导致尚某在某信息技术公司管理的代驾平台上存在违约行为，若某信息技术公司与案外平台签订有统一管理协议，亦应向尚某明确告知，故对于某信息技术公司的辩称不予采纳。

本案中需要注意的是，作为电子商务平台运营者，某信息技术公司既要保障乘客人身、财产安全，也不能损害司机的合法权利。对于某信息技术公司因其封禁尚某账户的行为对尚某造成的损失(自2022年2月25日至8月22日)，本院参照同类行业的一般收入水平、预期收益和本案的具体案情，酌情予以确定。

综上所述，北京市房山区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、确认某信息技术公司自2022年2月25日至8月22日将尚某工作账户封禁；

二、某信息技术公司于本判决生效后七日内赔偿尚某经济损失3000元；

三、驳回尚某的其他诉讼请求。

尚某不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：尚某与某信息技术公司签订的《用户服务协议(司机端)》系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应履约履行。二审中，某信息技术公司亦提交《代驾服务平台用户服务协议》，经对比核实，与尚某提交的《用户服务协议(司机端)》存在不一致的情况，应以司机端显示为准。

本案的争议焦点为：一审判决确认的经济损失数额是否妥当。尚某上诉称一审酌定数额过低，应以其账户被封禁前一日的营运收入作为计算依

据。本院认为，首先，代驾司机的行业性质决定其可以同时与多个服务平台建立服务合

同关系，从哪个平台接单具有一定的随机性与不确定性；其次，尚某应就其主张的营运损失承担举证责任，尚某向本院主张的损失计算标准仅为其账户封禁前一日收入，不具有长期性和稳定性；最后，一审法院参照同类行业的一般收入水平、预期收益和本案的具体案情酌情确定损失数额，并无明显不妥，本院予以维持。关于封禁期间，一审法院确认无误，法院亦予以确认。

综上所述，尚某的上诉请求不能成立，法院予以驳回。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

依法订立的合同对当事人具有约束力，双方的一切履行过程都要服从约定、信守约定。《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第二款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”本条是对履行合同原则的规定，是当事人在履行合同时应当遵循的基本准则，包括全面履行和诚实信用两项基本准则。全面履行原则要求合同当事人按照合同所约定的各项条款，全部而完整地履行合同义务，即合同约定什么内容就履行什么，一切违反约定的行为都属于对合同的违背。诚实信用原则要求一方当事人对对方当事人履行合同给予必要的协助，包括及时通知、互相协助与保守秘密等。

本案中，在《用户服务协议(司机端)》履行的过程中，没有证据和事实表明，尚某存在因履行代驾工作造成他人损害的过错情形，或者其他违反协议内容需要采取封禁账户措施的行为。某信息技术公司虽主张因尚某在案外公司存在与客户发生纠纷的行为，而某软件基于风险规避，对尚某采取封禁账户的限制措施。但需要注意的是，《用户服务协议(司机端)》中并未约定某信息技术公司与案外平台签订有统一管理协议的事项，某信息技术公司亦未在签约之时明确告知尚某若在案外平台发生纠纷将直接导致其在本平台的账户被封禁的后果。因此，即使尚某在其他网约车平台上被乘客投诉，某信息技术公司也

无权据此封禁尚某账户。在封禁账户后，某信息技术公司亦未在第一时间告知尚某封号原因、补救措施、申诉或复议的途径。

根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。某信息技术公司在没有合同约定的情况下无正当理由强行封禁尚某账户，对尚某的正常接单造成影响，故某信息技术公司的行为属于履行合同义务不符合约定的行为，应依法承担相应的违约责任。

一、尚某被封禁账户期间的经济损失如何确定

违约损害赔偿方式包括补偿性损害赔偿和惩罚性损害赔偿。一般的合同违约责任适用补偿性损害赔偿，惩罚性损害赔偿只在法律规定的特殊情况下才可以适用，不得随意扩大适用范围。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。本条规定了确定违约补偿性损害赔偿范围的基本规则，即赔偿实际损失规则和可预期损失规则。由此可知，违约责任中的损害赔偿责任的目的是对违约行为所造成的损害进行补偿，从而保护合同当事人的可期待利益，而非通过赔偿额外获益。换言之，在合同纠纷中，违约方仅就其违约行为给对方造成的损失承担赔偿责任，对由于市场风险和机会选择等因素造成的、双方当事人均不能预见到的损失，由于与违约行为之间不存在因果关系，故违约方对此不承担赔偿责任。

针对违约损害赔偿证明责任的分配问题，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条第一款规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。具体到本案中，尚某主张经济损失赔偿，应当举证证明“损失已经产生”和“损失金额的合理性”，如举证不力，则由尚某承担不利后果。

本案中，尚某认为应以其账户被封禁前一日的营运收入作为计算封禁账户期间每日财产损失的依据。但是显然，尚某主张的赔偿金额不具有合理性。

首先，代驾收入与其工作方式有关。由于代驾司机可以同时与多个代驾平台建立服务合同关系，司机可以按照自己的意愿选择代驾平台接单并获取收益，具有较强的独立性和自主决定权。也就是说，某信息技术公司对其账户的封禁并不会导致尚某无单可接，尚某仍可通过在其他代驾平台接单并获得收入报酬。

其次，代驾收入会受到市场因素的影响。影响代驾司机收入的因素包括司机的个人习惯，如在线时长、服务水平等，还有客观因素，如住所周边环境、淡旺季、天气状况等，其收入的稳定性相较一般服务行业不高。尚某主张的损失计算标准仅为账户封禁前一日收入，不具有通常性和长期性，不能作为确定一段时期经济损失的参考标准。

最后，根据举证责任原则，尚某应就其主张的营运损失承担举证责任。现尚某不能提供其被封禁前一年度的月/日平均收入作为计算经济损失标准的证据，应承担举证不能的法律后果。在此种情况下，当损失数额难以计算时，由法院依靠自由心证和经验法则进行合理判断，综合考虑尚某在他处的工作收入、同行业一般收入水平、市场风险因素、成本支出因素等酌情确定某信息技术公司对尚某的经济损失赔偿数额。

二、代驾司机的合法权益应如何保护

随着互联网技术的快速发展，网约车平台不仅给消费者的出行带来了巨大便利，而且给广大司机提供了工作岗位和经济收入。为最大限度地保障公众的出行安全，代驾平台有责任加强安全管理，但与此同时，对于代驾司机合法权益的保障同样不容忽视。

本案中，尚某虽在案外平台与乘客发生冲突，但尚无证据表明尚某存在过错或者有违反法律法规的行为，在某信息技术公司与尚某并无明确约定实行统一管理、牵连责任和某信息技术公司对尚某未尽到告知、通知义务的前提下，某信息技术公司无权封禁尚某账户。某信息技术公司以“我的地盘我做主”的姿态随意处置尚某账户，其行为已违反合同约定，侵犯了尚某的合法权益。

代驾司机是代驾平台主要的服务用户群体之一，代驾平台应对司机的基本劳动权益予以保障。结合本案案情来说，代驾平台应在服务协议中对代驾司机采取处置措施的情形进行提前约定，对于平台联合统一管理的情况还应当着重提示和说明；在采取处置措施后应详细告知司机原因和理由，并给予司机申诉的机会；代驾平台在采取处置措施时还应坚持措施大小与违规程度相适应的原则，对于处置措施明显超过必要限度的，应就此给司机造成的损失承担适度的赔偿责任。只有切实履行好平台职责，保护司乘双方的合法权益，才能推动代驾行业长久良性发展。

此外，对于代驾司机等新就业形态劳动者的合法权益还需要从法律司法层面予以保障。既要加快出台相关法律法规合理确定企业与劳动者的权利义务，还要在司法实践中尽快统一审理裁判尺度，以司法力量支持和规范新业态新经济，为代驾司机等新业态劳动者撑起“法治后盾”。

编写人：北京市房山区人民法院 房昕

网约车司机“绕路”行为的司法认定

—— 王某诉某科技公司、某人力资源服务公司服务合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

浙江省杭州市西湖区人民法院(2023)浙0106民初6458号民事判决书

2. 案由：服务合同纠纷

3. 当事人

原告：王某

被告：某科技公司、某人力资源服务公司

【基本案情】

某科技公司系某人力资源服务公司经营者。原告注册代驾平台成为会员时，平台自动生成用户、平台方(某科技公司)、服务方(某人力资源服务公司)三方签订的《代驾服务协议》。代驾司机与某人力资源服务公司签订劳务协议。2021年11月至2023年6月，原告使用某人力资源服务公司下单代驾服务合计82次，其中起点为某大厦终点为某小区的代驾服务共10次，该10次代驾费用为84元至151元不等。根据2022年9月20日行驶轨迹图显示，当日司机的实际驾驶路线与预估路线存在明显不合理偏差。该笔订单原告实际支付费用148元，其中3元使用优惠券抵扣。两被告自认经核查，该次服务司机确实存在行驶路线与规划路线不一致情形，当日预估收费为99元。

原告诉称，其因工作所需饮酒后常在夜间乃至凌晨使用某科技公司提供的代驾服务，使用过程中，发现司机经常有绕路不合理收费的情况，其支出100元以上的费用均为绕路所致。两被告应按诚实信用基本原则履行服务合同。因司机至少绕路20次，其行为构成欺诈。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款之规定，两被告应按每次500元的标准赔偿原告1万元，并退回多收费用。诉讼请求：(1)两被告向原告书面道歉。(2)两被告返还多收取的费用合计224元。(3)两被告赔偿原告1万元。两被告对原告的上述主张均不同意。

【案件焦点】

1. 司机代驾行为是否构成绕路；2. 绕路行为是否构成欺诈。

【法院裁判要旨】

浙江省杭州市西湖区人民法院经审理认为：根据某科技公司提交的订单信息及轨迹图，2022年9月20日的订单与其他同起讫点的相比，存在司机未按原规划路线行驶且实际行驶轨迹与规划路线有明显大幅偏移情形。某人力资源服务公司自认当日服务的预估费用为99元，其虽对代驾服务收费的构成及可能导致费用浮动的原因进行了说明，但原告当日支付的费用远远高于其他同时段、

同起讫点行程收取的费用，且超过预估费用的50%，明显超出费用计算的合理浮动区间。同时，在案并无任何证据证明代驾司机与原告曾就当日的行程路线变动有过协商。据此，2022年9月20日代驾司机确属存在绕路行为。原告关于司机存在多次绕路行为的主张依据不足，法院未予采信。鉴于司机是履行某人力资源服务公司的合同义务，实为某人力资源服务公司合同义务的履行辅助人。故司机行为之法律后果应由某人力资源服务公司承担。

欺诈行为是指经营者在提供商品或者服务中，采取虚假或者其他不正当手段欺骗、误导消费者，使消费者的合法权益受到损害的行为。具体到本案中，如前所述，代驾司机在2022年9月20日的代驾服务中存在绕路行为，既没有按照规划路线行驶，也没有经过与原告协商对路线进行调整，最终向原告收取畸高的费用，存在隐瞒、欺骗、误导原告之故意，且导致原告利益受损，构成欺诈行为。原告要求按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款规定增加赔偿的请求，法院予以支持。

浙江省杭州市西湖区人民法院依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

- 一、某人力资源服务公司返还王某费用52元；
- 二、某人力资源服务公司赔偿王某损失500元；
- 三、驳回王某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

网约车作为分享经济代表带来新经济红利的同时，新情况、新问题、新风险也随之而来，如对司机约束力不足，投诉渠道不畅、侵犯个人信息权、未及时消除安全隐患等。满足用户便捷、高效的需求、坚守民众安全、放心的底线，才是永恒的主题。只有在良性互动中强化规则导向，才能推动由粗放低效向经济规范的治理升级。随着《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》《关于深化道路运输价格改革

的意见》的陆续出台，国家对网约车发展规范与支持并重的态度进一步明晰。在此大背景下，笔者以期通过对个案的梳理与分析，在“个案—规范”的分析框架中，助推涉网约车市场主体权利义务关系的重构、平台责任框架的重建及行业的健康有序发展。

一、关于司机是否存在绕路行为的举证责任分配

绕路，即不走最直接的路，改由其他途径迂回过去。实践中，绕路主要表现为乘客凭借行程时长、费用收取、个人经验等因素对乘车体验的主观判断和最终得出的结论。在传统交通运输服务合同案件中涉及认为司机绕路发生的纠纷并不少见。而随着互联网技术的发展，地图类应用软件及打车软件内嵌导航规划路线系统的出现和优化使得乘车路线更为科学化、可视化及可对比化，司机是否绕路的判断标准变得更为透明、客观。据此，部分网约车平台即明确将绕路行为定义为不按照平台规划路线或者乘客指定的路线行驶。

司法实践中，该类案件的审理难点之一在于大多数乘客证据收集难度大，提交证据多停留于投诉记录、支付记录截图等层面，很少能够提交规划路线与实际行驶路线比对图等较为直观的证据证明存在绕路行为。同时，乘坐车次频繁，使用应用软件时间长，起讫点不一，司机隶属不同公司，行驶轨迹图、规划路线图、行程录音录像保存于平台公司乘客客观无法直接取得等因素，均导致乘客举证难上加难。民事诉讼证明责任分配的一般规则“谁主张，谁举证”已经不能完全保障此类案件中消费者的合法权益，反而容易成为平台公司推卸责任的理由。因而，关于举证责任分配，《最高人民法院关于认真学习贯彻实施消费者权益保护法的通知》中指出，人民法院要合理分配当事人的举证责任，既要充分运用举证责任倒置，解决当事人商品信息不对称的问题，充分保护消费者的合法权益，又要明确消费者的初步举证的义务，及时查明案情，分清是非责任。经营者不能提交充分证据证明商品没有质量问题，或者损害是由于消费者使用不当等原因造成的，应承担举证不能的不利后果。

基于此，因本案原告所诉司机存在多次绕路行为，法院在审理过程中，即先要求由原告明确其认为存在绕路的时间段、起讫点、不合理价格区间等要素

以固定其诉称绕路行为的具体情形，再由两被告就原告提交的信息要素一一查证、核实后台保存的行程时间、行程时长、行程地点、规划及行驶路线图、司机隶属情况等，并将查证内容作为证据提交质证、辩论。本案中，2021年11月至2023年6月，原告使用某人力资源服务公司下单代驾服务合计82次，其中起点为某大厦终点为某小区的代驾服务共10次，费用超过100元的共计四次。2022年9月20日原告支出的费用为151元。

二、关于司机是否存在绕路行为的认定

由于规划及实际行驶路线图属于电子证据，具有不稳定，易被破坏、篡改等特性，且实践过程中存在乘客更改路线未及时标注的可能性，因此，仅以规划路线与实际行驶路线对比图认定司机是否存在绕路行为并不周全。对绕路是否构成的认定应结合合同起讫点类似时段的行程对比，价格构成要素变化情况、价格合理浮动区间、行程录音录像、投诉反馈信息等具体的其他在案证据综合判断。

回到本案中，根据某科技公司提交的订单信息及轨迹图，2022年9月20日的订单与其他同起讫点的相比，存在司机未按原规划路线行驶且实际行驶轨迹与规划路线有明显大幅偏移情形。虽然当天的代驾行程未录音录像，但从原告于次日向某科技公司投诉及平台工作人员反馈的微信聊天记录截图中可看出，原告并未要求司机于该次行程中更改路线，司机亦未就路线的变更与原告有过协商。同时，某人力资源服务公司自认当日服务的预估费用为99元，其虽对代驾服务收费的构成及可能导致费用浮动的原因进行了说明，但原告当日支付的费用远远高于其本人行程记录中其他同时段、同起讫点行程收取的费用，且超过预估费用的50%，明显超出费用计算的合理浮动区间。因此，根据在案证据，认定司机2022年9月20日的代驾行为构成绕路。关于其余三次费用超过100元的行程。行车轨迹显示，三次均不存在实际行程偏离规划轨迹的情形；三次行程产生的实际费用分别为103元、110元、116元，对应的行驶时长为51分钟、39分钟、34分钟。一般而言，司机绕路的目的是通过增加行驶里程获取更多费用，客观上而言，该行为会一定程度延长行驶时间。但从上述三组数据

的比对中，未发现费用上涨与时间延长的正相关联系。另外，上述三次行程的后两次均发生于凌晨0时后，某人力资源服务公司就此平台公示的实际计费以发单时间为准，凌晨0时之后的基础起步价与其他时段起步价有所区别，该区别主要由不同时段的等候费变化导致，等候费的计算则涉及该时段能够提供服务的司机人数等变量。考虑到凌晨0时后在线司机数量的实际情形，其解释能够一定程度上对费用的收取进行合理说明。另外，行驶路线及收费的不一致可能由当日实际路况、天气情况、途经红绿灯数量及等待时长等具体变量导致。现有证据无法就原告所称代驾司机存在多次绕路的主张予以佐证，故原告的该项主张依据不足，法院未予采信。

三、关于司机绕路行为是否构成欺诈

欺诈行为是指经营者在提供商品或者服务中，采取虚假或者其他不正当手段欺骗、误导消费者，使消费者的合法权益受到损害的行为。《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款规定：“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。”《中华人民共和国价格法》第十四条规定：“经营者不得有下列不正当价格行为……利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易……”国家市场监督管理总局《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条规定：“经营者提供商品或者服务不得有下列行为……（十）骗取消费者价款或者费用而不提供或者不按照约定提供商品或者服务。”第十六条第二款规定：“经营者有本办法第五条第（七）项至第（十）项、第六条和第十三条规定行为之一的，属于欺诈行为。”

从上述法律、法规、规范性文件可知，《中华人民共和国消费者权益保护法》视域中“欺诈”的内涵及外延与民法范畴中的并不完全一致，这也直接导致《中华人民共和国消费者权益保护法》中关于欺诈的惩罚性赔偿制度不同于民法理论上的补偿性赔偿，其更加强调经营者对自己实施的欺诈行为应承担加

重后果，强调对经营者利用消费者信息不对称地位利用、诱使消费者作出错误意思表示的行为的惩罚，并因经营者的过错允许消费者获得实际损害赔偿之外的额外赔偿。结合上述要点及法律适用的效果，对于网约车经营范畴内欺诈的认定，应当综合考虑两个方面的因素：一是主观方面，欺诈者是否具有欺诈的故意；二是客观方面，欺诈者是否实施了虚构事实、隐瞒真相、采取虚假或者其他不正当手段欺骗、误导消费者的行为。同时，还可以考量消费者是否基于上述行为陷于错误判断并作出错误意思表示、与欺诈人进行民事交易行为。将最后一条考量因素单列、不作为必须考量的内容，系因为实践中，部分出行平台采取了捆绑信用卡且免密码支付的便捷结算方式，之后又拓展到支付软件代扣的支付方式，无须乘客结束行程后点击确认，导致乘客无法就其是否陷于错误判断作出错误意思表示进行合理充分说明。另外，平台等也设置了必须完成上一单结算方可开启下一轮服务的门槛，导致乘客为使用系统只能先行结算再投诉反馈。故而，过于强调最后一条考量因素将加重消费者的负担，不利于其权益的合法保障。

具体到本案中，客观上而言，2022年9月20日，代驾司机在代驾服务中存在绕路行为，通过不按照规划路线行驶的方式增加实际行驶路程，未按照约定提供服务，利用信息不对称的优势，最终向原告收取畸高的费用，其绕路行为构成采取虚假或者其他不正当手段欺骗、误导消费者的行为。主观上来看，如何证明经营者主观上是否存在欺诈的故意则涉及前文提及的举证责任分配问题。根据《最高人民法院关于认真学习贯彻实施消费者权益保护法的通知》的规定，有关举证责任的分配，消费者承担初步举证责任，只要消费者证明产品存在缺陷及经营者未告知即可初步认定经营者具有欺诈故意，若经营者提出不存在主观故意应由其对该主张承担举证责任，若无相反证据则应认定欺诈的故意成立。该条亦可参照适用于经营者提供服务的场景。本案中，在案证据能够初步证明司机未予原告协商未按照约定提供服务，两被告也自认当日司机确实存在行驶路线与规划路线不一致情形，当日预估收费为99元，而向原告实际收取的费用为151元。两被告虽抗辩原告主张绕路行为属欺诈无事实及法律依据，

但无法提供证据进一步证明司机不存在通过该行为获取不合理费用之故意，其抗辩不成立。综上，代驾司机2022年9月20日的绕路行为构成欺诈。

编写人：浙江省杭州市西湖区人民法院 宋歌

服务合同中消极行为构成欺诈的认定

——王某诉陈某服务合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省云浮市中级人民法院(2023)粤53民终1399号民事判决书

2. 案由：服务合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某

被告(上诉人):陈某

【基本案情】

某美容中心为陈某经营的个体工商户，其经营范围为美容服务、零售化妆品、保健按摩服务、健康咨询等，该美容中心现已注销登记。

陈某在经营某美容中心期间，在其微信朋友圈发布了再生发宣传资料。王某获知后，于2020年4月21日通过微信向陈某咨询再生发服务事宜。当问及如何生发时，陈某回复用产品刺激已萎缩的毛囊。陈某在未确定王某是否具备再生发条件的情况下，与王某约定，由某美容中心为王某提供再生发服务，一个疗程提供3次服务，服务费为7800元，王某依约支付了上述费用。收款后，某美容中心于2020年5月至8月为王某提供了一个疗程共3次的再生发服务。

在接受再生发服务期间，王某向陈某或其店员提出再生发效果不好的疑问。对此，陈某于2020年5月29日回复是因未激活的原因，且生发需要等待6个月的时间，而陈某的店员在2020年6月17日则表示需要再次激活，一个疗程是3次，一个疗程可以长出小毛发，但是能长多少要看毛囊基础，不会一点都不长。王某在某美容中心完成了一个疗程3次的再生发服务后，认为没达到再生发效果，要求陈某退还服务费。陈某表示，某美容中心的再生发服务是进行毛囊激活，没有毛囊的地方是做不了的，需要做毛囊移植才能长发，王某属于此种情形。因未达到再生发效果，王某要求陈某退款未果，遂起诉要求陈某退还服务费并进行三倍赔偿。

【案件焦点】

陈某经营某美容中心期间，为王某提供再生发服务是否存在欺诈。

【法院裁判要旨】

广东省新兴县人民法院经审理认为：王某在陈某经营的某美容中心接受了再生发服务，陈某在与王某交谈以及对外宣传，称其提供的美容服务具有生发的医疗效果，使王某陷入错误认识并向其购买再生发服务，构成欺诈。

广东省新兴县人民法院根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十条、第五十二条、第五十五条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

陈某应于本判决发生法律效力之日起七日内退还服务费7800元及赔偿损失23400元给王某。

陈某不服一审判决，提起上诉。

广东省云浮市中级人民法院经审理认为：陈某通过微信朋友圈发布再生发服务广告的方式宣传再生发服务，王某据此向陈某了解再生发服务，得到了“用产品刺激已萎缩的毛囊再生发”的回复，王某为此向对方支付了7800元的再生发服务费。基于再生发服务的消费者是以再生发为目的，作为服务的提供者，在与消费者确立服务合同时，应查看消费者的实际状况，并据此对是否符

合再生发条件作出判断后如实告知消费者。但本案中，陈某在与对方确立服务合同前并未就王某当时的情形能否再生发告知对方。而在王某发现没有再生发效果，向陈某及其员工咨询时，被告知需要再次激活，但经过一个疗程的激活后仍未达到再生发的效果。据此，由于陈某在经营过程中宣传可刺激已萎缩的毛囊再生发，而在确立合同前和履行合同过程中，陈某及其员工未就王某是否符合再生发条件如实告知王某，存在欺诈行为。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款之规定，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者接受服务费用的三倍。据此，陈某应返还服务费7800元，并按上述服务费金额的三倍即23400元向王某予以赔偿。

广东省云浮市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

我国民法的赔偿原则以填补损失为主，惩罚性为辅，但对于消费领域的欺诈行为，法律作了惩罚性的明确规定，《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款规定了经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，消费者可向经营者主张三倍以内的赔偿。经营者的欺诈行为是适用惩罚性赔偿的条件，消费者要求经营者三倍赔偿的，关键在于审查经营者的行为是否构成欺诈。

民事法律领域的欺诈，指一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事行为。一般表现为积极的行为，但满足一定条件的，消极行为也构成欺诈。对此，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第二十一条规定，负有告知义务的人故意隐瞒真实情况，致使当事人基于错误认识作出意思表示的，构成欺诈，实际是承认了消极行为构成欺诈的法律依据。根据前述法律规定可知，消极欺诈的表现是指行为人有义务说明而故意不作说明，其后果是误导了对方作出错误的判断，损害了对方当事人的知情权与选择权。

在消费服务领域中，对于积极行为的欺诈，需审查的是行为人是否实施了

欺骗性质的行为，如作虚假的宣传。对于消极行为的欺诈，由于其表现形态为不作为，故何时的不作为才能达到欺诈的要求是值得思考的。笔者认为，在司法实践中应就当事人是否存在以下情形进行审查：首先，应审查是否违反法律规定。例如，某些行业规定了经营许可制度，但经营者未取得相关许可的。其次，应审查当事人是否违反合同约定。合同是双方确立合同关系的凭据，反映当事人的意思表示，在合同规定了一方当事人应履行告知义务，而该当事人隐瞒了真实情况，且误导对方作出意思表示的。最后，应审查是否违反诚实信用原则。诚实信用原则是确立民事行为的基本原则，消费服务涉及广大消费者的权益，更应遵循此原则性规定。有些专业性较强的服务合同，常要求服务对象需满足一定的客观条件，否则无法达到服务效果，基于诚实信用原则的要求经营者应向对方说明。又如，在合同履行过程中，某些情况发生变化导致合同履行无法达到消费者原来设想效果的，经营者也应向对方如实告知。

本案中，陈某经营的某美容中心提供的再生发服务的方法是激活毛囊，即以服务对象的激活区域存在毛囊为前提。再生发服务合同内容本身具有较强的专业性，对于该专业性判断并不能苛求消费者独立完成，本案中涉及的“是否存在毛囊”的判断本身就属于专业性较强的问题，需由经营者作出判断。据此，在与消费者确立合同前，经营者应该查看对方是否具备上述条件并如实告知对方。陈某认为王某进行再生发服务的区域没有毛囊，故无法激活再生发，但在确立合同及履行合同过程中均未如实告知王某，隐瞒真实情形，其行为构成了消费欺诈。

编写人：广东省云浮市中级人民法院 李艳徽

直播带货领域中的行业交易习惯如何认定

—— 某科技公司诉某健康管理公司服务合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终3342号民事判决书

2. 案由：服务合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某科技公司

被告(上诉人): 某健康管理公司

【基本案情】

2021年2月26日, 某科技公司(乙方)与某健康管理公司(甲方)分别签订两份《电商直播合作协议》和一份《合同补充协议书》, 约定甲方于2021年3月5日为“A 品牌海苔卷虾”产品提供直播服务、于2021年3月20日为A 品牌鱼皮产品提供直播服务, 主播为B, 单品直播时长不低于行业通行标准5分钟。同时, 合同还对双方的佣金比例及违约金进行了约定。

关于“海苔卷”直播, 某健康管理公司于2021年3月3日通知某科技公司改期, 后某科技公司与某健康管理公司协商取消该产品的直播服务。

关于“鱼皮”直播, 双方均认可该产品的直播时间在2021年3月21日凌晨00:26, 全长约6分钟, 某健康管理公司称该主播是从2021年3月20日18时到2021年3月21日不间断的同一场直播, 属于行业里约定俗成, 某科技公司不认可。

2021年3月1日，某科技公司分两笔向某健康管理公司支付两款产品的直播服务费合计20万元，某健康管理公司于2021年3月22日、4月13日已向某科技公司退还共计81945.39元（海苔卷服务费10万元扣除鱼皮产品的佣金18054.61元）。

【案件焦点】

某健康管理公司未按规定安排“鱼皮”在2021年3月20日进行直播是否属于违约。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：合同生效后，当事人就合同履行内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。本案中，关于“鱼皮”直播，某健康管理公司称“合同没有约定任何排期放在第多少个，只要是B主播20日18:00的连续性直播带货一直到下播为止，这是行业约定俗成的规定”，某健康管理公司提出该主张来支持其不存在违约行为之抗辩，就应该对此“交易习惯”及某科技公司在订立合同时应该知道该“行规”等承担举证责任，但某健康管理公司未在法定期限内提交相关证据，应承担举证不能的后果；某科技公司据此要求某健康管理公司承担违约责任2万元，于法有据，一审法院予以支持。关于某科技公司所称3月20日安排人员跟进产生损失2万元，未提交证据佐证，一审法院不予支持；虽未在约定时间，但某健康管理公司已安排了直播，某科技公司要求重新直播，于法无据，一审法院不予支持。鉴于某健康管理公司安排了直播，但未在约定的时间直播，应承担违约责任，某科技公司要求返还服务费，于法无据。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百一十一条之规定，判决如下：

- 一、某健康管理公司于判决生效后七日内赔偿某科技公司违约金2万元；
- 二、驳回某科技公司的其他诉讼请求。

某健康管理公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：合同生效后，当事人就合同履行内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。本案中，关于《电商直播合作协议》及《合同补充协议书》项下“A 品牌鱼皮”产品直播，某健康管理公司主张合同没有约定具体产品排期放在第多少个，只要B 主播20日18:00的连续性直播带货一直到下播为止前播出“A 品牌鱼皮”即可，即便21日凌晨直播亦应视为某健康管理公司按合同约定履行了合同义务，这是行业约定俗成的规定。某科技公司对此不予认可，认为某健康管理公司应当按照合同约定的时间履行合同义务，产品播出的时间亦直接影响产品的销售额。根据《电商直播合作协议》及《合同补充协议书》有关约定，再结合某健康管理公司自称其专业从事直播经纪活动来看，某健康管理公司应就此“交易习惯”以及某科技公司在订立合同时应该知道该“行规”予以举证证明。现某健康管理公司未能提交相关证据证明，应承担举证不能的后果。某健康管理公司未按照合同约定的时间进行直播，构成违约。综合合同的实际履行情况，一审法院判定某健康管理公司支付的违约金数额适当，本院予以维持。某健康管理公司主张其不存在违约，缺乏依据，本院不予支持。

综上所述，某健康管理公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

作为近年来新兴起的商业模式，直播带货的热度持续居高不下。不同于传统销售的规范，直播带货在商业模式、交易结构等方面均处在摸索阶段，在保证市场规范经营、公平竞争之余，如何引导产业良性发展、激发生产要素活动与动力亦是司法机关不可忽视的命题。

本案的争议焦点在于某健康管理公司未按规定安排“鱼皮”在2021年3

月20日进行直播是否属于违约?某科技公司在抗辩中主张2021年3月21日凌晨00:26分的直播系与2021年3月20日晚间开始的直播为同一场,符合直播带货行业的交易习惯,故其不存在违约的情形。故如何认定直播带货行业中的交易习惯成为本案审理的关键。

交易习惯是对民商事主体在实践中反复适用的做法的归纳、抽象,能够得到普遍的认可和尊崇。但并非所有的反复性做法均能被认定为交易习惯,依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第二条,交易习惯分为当事人间的惯常做法、特定地域(行业)习惯两类。前者的范围限定在当事双方,应当从当事人之间是否形成了此种经常使用的习惯做法、当事人是否具有受其约束的内心确信,以及此种习惯做法是否合法有效等方面加以审查认定;后者的范围不局限在当事双方间,而是扩大至特定的地域(行业)。在认定时,一方面,需要满足“在交易行为当地或者某一领域、某一行业通常采用”的客观要件;另一方面,需满足“为交易对方订立合同时所知道或者应当知道”的主观要件。就适用顺位而言,当事人间的惯常做法较之后者更具针对性,也更接近于当事人之间的合意,因此当事人间的惯常做法应优先特定地域(行业)习惯进行适用。本案中,某健康管理公司所主张的交易习惯实际为特定直播带货领域的交易习惯,其需满足客观及主观两项要件。

交易习惯并不具有普遍意义上的约束力,在性质上仍属于“事实”的范畴,原则上仍应适用“谁主张,谁举证”的民事诉讼一般规则。提出交易习惯主张的一方当事人应当对交易习惯是否存在、具体内容以及是否可以约束相关主体完成举证,否则将承担诉讼上的不利后果。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第二条第二款对此予以了明确的规定。本案中,主张直播行业领域交易习惯的某健康管理公司应就该等交易习惯是否存在、某科技公司是否知晓等进行举证,在某健康管理公司举证不能的情况下,人民法院判定应以合同约定时间进行直播并无不妥。

值得注意的是,司法机关在审查交易习惯时,不仅要注意认定的交易习惯

不能违反法律、行政法规的效力性强制性规定，也要注意结合交易领域的特点对交易习惯的公平合理性进行考量，只有合法、合理的习惯才能成为解释合同的依据和填补漏洞的方法。如此才能引导合同当事人形成符合公平原则和诚信原则的交易习惯，构建和维护公平和诚信的交易秩序。

编写人：北京市朝阳区人民法院 江宇

二十三、准合同纠纷

64

错误汇款所有权归属的司法认定

—— 周某诉何甲、某银行涪陵分行不当得利案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第三中级人民法院(2024)渝03民终61号民事判决书

2. 案由：不当得利纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 周某

被告(上诉人): 某银行涪陵分行

被告(被上诉人): 何甲

第三人: 何乙

【基本案情】

周某与第三人何乙系合伙人，共同开办了某食品厂，第三人何乙负责该厂的财务管理，2023年10月16日，周某欲将其收回的榨菜销售款32万元通过手机银行转账给第三人何乙，用于发放该厂20余名职工1月至8月的工资。当日11时11分30秒，周某通过手机银行将其在某银行涪陵分行处开设的账户中的

32万元转给第三人何乙，但因操作失误将该款转入了被告何甲在被告某银行涪陵分行处开设的账户中，同日11时11分40秒，某银行涪陵分行的系统自动将该款扣划至某银行涪陵分行开设的账户中。事后，周某通过电话询问第三人何乙是否收到转账32万元，得知第三人何乙未收到此款后，同时电话询问何甲，被告何甲告知本人并不知情，且何甲通过查询，其账户中并不存在32万元存款。周某遂于当日15时8分向重庆市涪陵区公安局报警，同时通过法院执行局查询，得知何甲开设的账户未被司法机关查封。后，周某通过多方查证才发现该款已转账至某银行涪陵分行的账户中，经周某向某银行涪陵分行、何甲追索无果，遂起诉法院。

另查明，何甲与某银行涪陵分行签订了《最高额担保个人借款合同》，合同约定，借款人未按约定及时归还借款本息，贷款人可直接从借款人在某银行涪陵分行各机构开立的账户中划收。截至2023年11月13日，何甲仍尚欠某银行涪陵分行借款本息2139552.55元未还，某银行涪陵分行在划走涉案款项前已将何甲在某银行涪陵分行开设的账户设置为自动划收账户。

【案件焦点】

某银行涪陵分行扣划周某误转入何甲银行账户的钱款是否构成不当得利。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第一百二十二条规定，因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求返还不当利益。周某因操作不当将款项错误转入了何甲的银行账户中，同时，某银行涪陵分行将何甲的涉案账户设置了自动划收款项功能，因此周某转出的款项实际被某银行涪陵分行占有，导致周某利益受损，虽然周某将款项转入了何甲账户中，但仅10秒钟被银行系统划走，何甲并不知晓，也无占有或处分的意思表示，更无将该款用于归还某银行涪陵分行借款的行为，故何甲未实际取得不当利益，依法不构成不当得利，不应承担返还责任；某银行涪陵分行虽然与何甲之间存在合同约定可以直接扣划何甲账户中款项用于归还借款的权利，但是，

周某因错误转入何甲账户的款项并非系何甲的合法财产，而某银行涪陵分行划走的款项属周某的款项，导致周某利益受损，某银行涪陵分行划走该款相对于周某来说没有法律根据，周某请求某银行涪陵分行返还该款，但某银行涪陵分行拒绝返还的行为构成不当得利，依法应承担返还不当利益的民事责任。

重庆市涪陵区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百二十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

- 一、某银行涪陵分行在本判决生效后五日内返还周某不当得利32万元；
- 二、驳回周某的其他诉讼请求。

某银行涪陵分行不服一审判决，提起上诉。

重庆市第三中级人民法院经审理认为：本案应把握以下关键问题。

一、关于案涉款项是否为误转

要判定周某就案涉款项是否享有民事权益，须以判定案涉款项的归属为前提；而本案中案涉款项的归属，取决于周某向何甲账户转款的行为是否确系误转。本案中，从周某、何甲、何乙的陈述，可以看出周某错转账后当即发现错误，即向收款人何甲告知错误转账事实，随后报警，向一审法院查询执行情况，故能够认定周某系错误转账。从周某手机银行页面显示亦能看出，何甲与何乙的首字母均为H，又因查询时均在同一界面，极易造成混淆，实践中通过手机银行汇款后再次给该账户汇款无须重新输入收款人信息，致使错误汇款成为可能。周某在发现转错款项后与何甲取得联系，何甲认可上述款项系误转，并已用实际行动表示其无接受、占有上述款项的意思表示。故周某关于案涉款项系误转的诉讼主张符合常理和日常逻辑，且与上述事实相符，应予认定。

二、周某对案涉款项享有何种权利；案涉款项能否纳入何甲的责任财产

货币系种类物，在通常情况下，占有即所有，应当以占有状态确定货币的权利。但在本案中，由于周某向何甲转款32万元系误转所致，周某对于转款行为不具有真实的意思表示，何甲亦缺乏接受该款项的意思表示，该误转行为仅系事实行为，并非法律行为，因此周某的误转款并不当然产生该款项实体权益变化的法律效果，该款项的实体权益仍属周某所有，周某对案涉款项享有所有

权。案涉款项虽转入何甲账户，但因该账户已被某银行涪陵分行设为自动划扣账户，何甲对误转入该账户的涉案款项并未实际占有、控制或支配，周某误转入案涉账户的款项并未与何甲财产出现混同，使其得以与其他款项相区别，已属特定化款项，不宜认定何甲为该款项的实际权利人，案涉款项不应纳入何甲的责任财产。在涉案款项不属于何甲的责任财产的情况下，某银行涪陵分行依据其与何甲的约定，划扣周某的财产就构成不当得利，其应当予以返还。

在已经查明案涉款项的实体权益属周某的情况下，直接判决停止对案涉款项的划扣以保护权利人的合法权益，该处理方式符合立法目的，也有利于节省司法资源和当事人的诉讼成本；如认为何甲在本案中构成不当得利，仍要求周某再通过另一个不当得利之诉寻求救济，除增加当事人诉讼成本、浪费司法资源外，并不能产生更为良好的法律效果和社会效果。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

为了保障资金安全，控制交易风险，银行在出借款项时往往会和借款人在金融借款合同中约定“借款人未按约定及时归还借款本息，贷款人可直接从借款人在某银行涪陵分行各机构开立的账户中划收”，即在未按约定偿还借款本息的情况下，银行有随时扣划的权利，避免不良债权的产生。但银行扣划他人误转入借款人银行账户的钱款，该行为关系到债权人、债务人、第三人合法权益的保护，笔者结合本案案例，对此进行探讨。

一、错误汇款返还请求权基础

认定错误汇款，应具备以下条件：存在合理的错误汇款原因、符合一般理性人的汇款常识、汇款人与收款人无恶意串通等逃避债务行为。汇款人因错误汇款如何救济，笔者认为错误汇款法律关系本质上构成不当得利。《中华人民共和国民法典》第九百八十五条规定“得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益”，不当得利是指无法律根据使他

人受到损失而自己获得利益的事实。错误汇款行为是不当得利之债产生的原因，所涉及的法律关系为指示给付关系，属于给付型不当得利的类型之一，其构成要件同样要满足以下五个要件：(1)一方获得利益，在错误汇款问题中，利益实际上是当事人自他方受领的给付，应有之义是产生增加他人权益的法律效果。(2)一方遭受损失，“损失”之要件在传统不当得利与错误汇款导致不当得利并无本质区别，类型范畴相同。(3)无法律上的原因，是否具有法律上的原因是不当得利构成的关键。(4)因果关系。(5)多方参与，传统不当得利仅有双方参与，错误汇款情形中汇款人、汇出银行、汇入银行、收款人存在多方参与不当得利法律关系。

二、错误汇款所有权归属

正是因为错误汇款存在这种多方情况，从而引出本文探讨的核心问题，即在满足不当得利构成要件的情况下，错误汇款人应向谁主张不当得利返还，扣划银行还是收款人。

我国在法律上并没有对货币所有权归属作出明确的规定，民法学研究通说采：货币占有即所有原则，即货币之占有与所有合二为一，这是因为货币的固有本质属性是流通，所以在流通过程中以及在现实占有之外，不宜存在其他人拥有所有权。同时，因为交易上的需要，使得货币之占有与所有不得相分离，以此来保障货币的流通机能，使交易得以顺利进行。故货币之所有权必须与其占有相融合、一致的原因是为了交易上的需要。但是在现在以存款货币转账汇款为主的货币流转中，错误汇款的所有权归属问题却日益增多。结合本案案例，本案只对存款货币所有权归属进行分析。存款货币就是通过网上银行进行流转的货币，其本质上也是属于货币。不同于传统的实物货币如现金交易的流转方式，存款这一货币形式主要依靠账户转账、平台支付等方式实现流转。但在错误汇款的情况下，若该错误汇款符合“特定性”要件，则不适用“占有即所有”原则，对于特定化的判断标准，司法实践中有三种认定标准，第一种是账户要以特户、封金、保证金等特殊形式特定化；第二种是错汇款项未与其他资金混同；第三种是错汇款项进入账户之前账户已被冻结。前述三种从严到宽的

认定，其中第一种标准过于严苛，实践中错误汇款很难满足该特定化条件。第二种标准重点在于该账户在错汇款项之前未存在其他款项。第三种标准相对于第二种进一步放宽了对账户内其他款项的要求，认为在账户已被冻结的情况下，款项转入时间、金额银行系统均能显示，使得错汇款项特定化。

银行从借款人账户内扣划资金的权利来源于与借款人的合同约定，但该权利的行使并不是不受限制，在错误汇款特定化的情况下，银行便不能对该笔汇款进行扣划，否则将侵犯汇款人合法权益。

三、关于本案的具体分析

本案中，在何甲对银行所欠债务到期未偿还的情况下，案涉银行账户已被某银行涪陵分行设定为自动扣划账户，该账户的款项何甲无法支配，所以即出现本案在汇款人周某错误汇款后10秒内，银行即自动扣划。对何甲本人来说，其根本不知道钱款汇入，欠缺占有的主观意思表示，案涉银行账户被设定为自动扣划账户，收款人无法对账户内的款项进行支配，故何甲并未实际控制、占有和支配款项，且案涉款项在转入该银行账户时并未与何甲的财产发生混同，符合特定化的判断标准，故不适用“占有即所有”原则。案涉错汇款项并不属于何甲的责任财产，仍属于汇款人周某的财产，某银行涪陵分行依据其与何甲的约定，划扣周某的财产就构成不当得利，其应当予以返还。

编写人：重庆市第三中级人民法院 余云中

重庆市涪陵区人民法院 董怡